InDret

El coste de educar: expulsar a un alumno no es gratis

Comentario a la STS, 1ª, 9.12.2003

Fernando Gómez Pomar
Facultad de Derecho
Universitat Pompeu Fabra

Working Paper nº: 219
Barcelona, abril de 2004
www.indret.com

Las entidades privadas que se dedican, con y sin ánimo de lucro, a la noble tarea de educar a nuestros niños y jóvenes precisan de un ámbito importante de libre autoorganización de sus actividades, funcionamiento y disciplina internos. Sin tal capacidad de decisión sobre el terreno, el cumplimiento eficaz de los objetivos educativos perseguidos podría verse seriamente comprometido. Pero sus decisiones en esta materia, al igual que los de otras entidades privadas, incluso en ejercicio del derecho fundamental de asociación[1], no son enteramente libres e incondicionadas, no pueden sustraerse por entero a pautas externas de contraste y enjuiciamiento, como ha reconocido tanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional[2] como la del Tribunal Supremo[3].

La sentencia del Tribunal Supremo de 9.12.2003 enjuicia un caso de expulsión arbitraria (el calificativo no es mío, sino del Tribunal Supremo) de un alumno adolescente (la sentencia no precisa la edad, pero al tratarse de un alumno de tercer curso de BUP, debía estar por los 16 años) por parte de un centro escolar privado.

Y el remedio escogido por el Tribunal Supremo para reaccionar frente a la conducta arbitraria del Colegio, en vulneración (el calificativo sigue sin ser mío, sino del Tribunal Supremo) de derechos constitucionales, va a ser la indemnización del daño moral padecido, al menos en el criterio del Tribunal, por el propio alumno y por sus padres.

Ya en estas mismas páginas de InDret[4], hace algún tiempo, avancé la hipótesis de que el Tribunal Supremo emplea la condena a indemnizar el daño moral para sancionar conductas (socialmente o, cuanto menos, en su personal criterio de lo que la sociedad considera) reprensibles, pero que causan, típicamente, un daño patrimonial, un impacto patrimonial negativo, bajo o muy bajo. Probablemente nos encontramos aquí, junto a otros aspectos de orden diverso, en cuanto a las garantías exigibles a la conducta sancionadora de los centros escolares privados, ante una muestra más de esa actitud. Expresada, no obstante, en un caso alejado de los que habían venido siendo el núcleo central de asuntos en los que la función sancionadora de los daños morales era más patente: las agresiones sexuales y las muertes de personas sin ingresos.

Veamos si el relato de los hechos y de las vicisitudes judiciales subsiguientes permite confirmar esta hipótesis.

---

[1] Véase Pablo Salvador, Ingo von Munch y Josep Ferrer, *Asociaciones, derechos fundamentales y autonomía privada*, Cívitas, Madrid (1997).

[2] SSTC 104/1999, 96/1994, 218/1988, entre otras. Muy crítico con esta jurisprudencia, y en general con las restricciones a la libertad autoorganizativa de las asociaciones, Luis María Díez-Picazo, *Sistema de Derechos fundamentales*, Cívitas, Madrid (2003).

[3] SSTS, 1ª, 16.6.2003, 16.12.1991, 17.12.1990, entre otras.

[4] Fernando Gómez, "Daño moral", *InDret* 1/1999.

1. El relato de hechos

El joven Ángel Daniel ingresó en septiembre de 1994 como alumno en el centro privado no concertado Colegio Rías Altas, cuya entidad titular era la Sociedad Cooperativa Limitada "Colegio Rías Altas".

A comienzos de noviembre de aquel mismo año, el alumno en cuestión fue expulsado por la dirección del Colegio, bajo la sospecha de consumo de drogas en el recinto escolar. La expulsión fue precedida de una mínima actividad instructora previa a la sanción (3 folios, en la caracterización cuantitativa del Tribunal Supremo), pero con omisión clara de conductas de instrucción del expediente sancionador que el Tribunal Supremo considerará finalmente imprescindibles: falta de información puntual al interesado o a sus padres acerca de los cargos imputados y de la persona del instructor; falta de audiencia; falta de contradicción probatoria.

Merced a la mediación de la Inspección de Enseñanza de A Coruña, Ángel Daniel pudo incorporarse en febrero a otro centro de la localidad gallega, en régimen de enseñanza nocturna, en apariencia (la sentencia no lo aclara, pero no se alega como daño indemnizable) con aprovechamiento suficiente para acceder al curso siguiente de las enseñanzas medias.

En 1996, Ángel Daniel, y sus padres, Antonio y Sara, demandan a la Sociedad Cooperativa Limitada "Colegio Rías Altas", exigiendo una doble tutela jurisdiccional. De un lado, la declaración de que la expulsión vulneró los siguientes derechos constitucionales: derecho a ser informado de la acusación, a la defensa, a la presunción de inocencia y a la contradicción probatoria (todos en el art. 24 CE); legalidad y tipicidad de infracciones y sanciones (art. 25 CE); derecho a la educación (art. 27 CE). De otro, la condena a la demandada a indemnizar a los tres demandantes los daños y perjuicios sufridos, en cuantía que se determinaría en ejecución de sentencia.

El Juzgado de Primera Instancia número dos de A Coruña acogió la demanda en lo referente a la declaración de vulneración de los derechos constitucionales de los artículos 24 y 27 CE, así como en la pretensión indemnizatoria ejercitada por los demandantes.

La Audiencia Provincial de A Coruña, ante el recurso de la demandada, mantuvo el pronunciamiento declarativo de la sentencia de primera instancia pero revocó íntegramente la condena indemnizatoria.

Los demandantes recurren en casación y el Tribunal Supremo estima el recurso, condenando a la Sociedad Cooperativa Limitada "Colegio Rías Altas"a pagar a los demandantes daños morales por importe de doce mil euros (12.000 €).

2. *El régimen disciplinario de los Colegios privados y el control judicial*

Los centros escolares privados son titulares del derecho constitucional a la libertad de asociación (además del de la libertad de enseñanza de que gozan sus entidades titulares y del de la libertad de empresa). Tal y como señala la jurisprudencia del Tribunal Constitucional[5], las entidades que, además de, o en lugar de, la pura persecución de lucro o beneficio económico, incorporan una finalidad de cooperación o relación recíproca entre personas, están comprendidas dentro del ámbito de protección del art. 22 CE.

Por lo anterior, es claro que la Sociedad Cooperativa Limitada "Colegio Rías Altas", titular del derecho de asociación, del derecho de libertad de enseñanza y del derecho de libertad de empresa, tiene un amplio espacio de discrecionalidad y libertad de autorganización, que comprende no sólo la estrictamente orgánica o de personalidad jurídica, sino también la del régimen interno de desarrollo de la actividad educativa (por descontado, ajustada a las normas constitucionales, legales y reglamentarias en la materia y a las legítimamente ejercidas potestades públicas educativas y demás de aplicación a la actividad). En ese espacio se comprende sin duda el régimen de conducta académica y disciplina de su alumnado. Y ello con fundamento tanto en la libertad de asociación como en la libertad de enseñanza y, acaso, en la libertad de empresa.

Como ya ha sido analizado, convincentemente y por extenso, por otros[6], en relación con las entidades asociativas, esta amplia libertad organizativa no implica, en el sistema constitucional español tal y como ha sido entendido por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, el otorgamiento de un espacio exento de control exterior, en particular, de control judicial *ex post* de las decisiones adoptadas en uso de la libertad de autorregulación de composición, funcionamiento y actividades.

Esta misma situación viene a ser confirmada por la sentencia de 9.12.2003 para los centros escolares privados que no reciben fondos públicos: en las decisiones privadas que comportan un elemento sancionador, los derechos constitucionales reconocidos en el art. 24 CE constituyen un límite intrínseco a la capacidad autoorganizativa de los centros escolares privados (o de otras entidades privadas de base asociativa). Al sancionar, aunque sea con trascendencia esencialmente interna[7] (la privación temporal de prestaciones asociativas o la expulsión), los centros educativos privados deben informar de los hechos imputados, oír al alumno -y a sus padres- y permitir sus alegaciones y su defensa. Por ejemplo, en materia no muy alejada, la Ley 27/1999, de 16 de julio, de cooperativas, exige en su art. 18 garantías frente a las sanciones a los

[5] SSTC 23/1987 y 96/1994, en especial la segunda, por cuanto positivamente admite a las cooperativas en el círculo de beneficiarios de la tutela del art. 22 CE.

[6] Pablo Salvador, Ingo von Munch y Josep Ferrer, *Asociaciones, derechos fundamentales y autonomía privada*, Cívitas, Madrid (1997). En general, sobre la relación entre autonomía privada y derechos fundamentales, véase Jesús Alfaro, "Derechos fundamentales y autonomía privada", ADC (1991).

[7] Esto es, no afecta a la capacidad de ejercitar derechos, realizar actividades y, en definitiva, incrementar su situación de utilidad, fuera de la organización.

socios, y en particular frente a la expulsión, en cuanto a la instrucción del procedimiento sancionador (audiencia, información escrita, contradicción) y a la decisión sancionadora (órgano sancionador, recursos). Y el art. 21.1.c) de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, del Derecho de asociación, atribuye a todo asociado el derecho a ser informado, a ser oído y al carácter motivado, en todo caso de sanción impuesta por los órganos de la asociación.

Algo más dudosa resulta, en la sentencia que se comenta, la sujeción del régimen disciplinario académico de los centros escolares privados a los principios del art. 25 CE: el de legalidad en sentido amplio, como previsión previa y escrita de las conductas sancionables, pues en sentido estricto es inaplicable fuera de las sanciones del poder público, y el de tipicidad. La sentencia del Juzgado de Primera Instancia omitió declarar la vulneración de tales garantías por parte del Colegio, y tal pronunciamiento no fue luego objeto de recurso. Por otro lado, la sentencia no proporciona información alguna acerca de la previsión de conductas sancionables en un reglamento de disciplina académica del Colegio en cuestión, y ni siquiera se menciona la existencia o inexistencia de un reglamento como tal[8].

Una reciente sentencia de la sala 1ª del Tribunal Supremo (STS, 1ª, 16.6.2003) da por buenas las consideraciones de la Audiencia que entiende sujeta a los principios de tipicidad y legalidad la actuación sancionadora interna de las entidades privadas: "*Que todo derecho sancionador participa de la naturaleza y caracteres del Derecho punitivo, por lo que debe ajustarse a los principios de legalidad y tipicidad, ya que no es posible entender que una sanción pueda ser consecuencia de una actuación que no se encuentra precisamente tipificada o de la infracción de un deber desconocido, ya que en tal caso se cercenaría en gran manera el derecho de defensa.*" Y el Tribunal Supremo ratifica que la previsión estatutaria no describía con la necesaria precisión y claridad las conductas merecedoras de expulsión, con el efecto de que la imposición de la sanción quedaba a la libre decisión de los órganos sociales, lo cual impedía que en el seno de la asociación pudieran manifestarse de forma eficaz comportamientos de oposición a las personas que ostentaban las facultades de dirección en los correspondientes órganos asociativos.

Desde luego, es muy dudoso, a mi juicio, que las exigencias de previsión estatutaria (o similar) y tipicidad de conductas sancionables y sanciones[9] sean trasladables de forma inmediata y completa desde la disciplina interna de las estructuras asociativas a la disciplina académica de los centros escolares. Varias consideraciones son necesarias aquí. La libertad de enseñanza probablemente permite, al ir de la mand de la libertad de asociación, un plus de libertad de organización y gestión respecto del que ampara esta última libertad por sí sola. De forma más importante, la aplicación de los aludidos principios del art. 25 CE, tal y como señala el propio Tribunal Supremo, se pone al servicio del funcionamiento interno democrático[10], del ejercicio de

[8] La página *web* del centro escolar tampoco suministra información a estos efectos.

[9] Por ejemplo, el mencionado art. 18 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de cooperativas, las impone expresamente para las mismas.

[10] Que hoy impone con carácter general el art. 2 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, del Derecho de asociación.

derechos "políticos" internos, y de la posibilidad de articular, de forma libre y no condicionada por una amenaza siempre latente de expulsión, una oposición interna en el seno de la estructura asociativa. Este objetivo, palpablemente, no puede perseguirse razonablemente en un centro escolar privado: no cabe el uso estratégico de las reglas sobre régimen académico para, pongamos por caso, aplastar la oposición "política" de los alumnos. Por otro lado, no se puede olvidar el hecho de que los centros educativos privados, al contrario que muchas asociaciones, son agentes en un mercado de servicios educativos, en el cual existe notable competencia por parte de otros proveedores, privados y públicos, de servicios que gozan de un alto grado de aptitud sustitutoria de los que pueda ofrecer el presunto transgresor de derechos constitucionales.

Una observación general es pertinente, creo, en relación tanto con las garantías del art. 24 CE (estas sí, claramente aplicables, según el Tribunal Supremo, a las decisiones de expulsión de centros escolares privados) como con las del art. 25 CE, y su aplicación traslaticia a las llamadas "sanciones privadas". Todas esas garantías, y otras, nacen asociadas a la imposición, por el poder público, de sanciones muy costosas en términos personales y sociales (privación de libertad, castigo corporal, incluso la muerte en muchos países). Cuanto más costosa socialmente es una sanción, más trascendencia tiene la verdad material de los hechos realmente acaecidos. Por ello, más sentido poseen las garantías procedimentales que tratan de reducir el coste del error en la imposición de sanciones. Además, las sanciones más elevadas se imponen de ordinario a las conductas socialmente más dañinas, esto es, aquellas respecto de las cuales la prevención es comparativamente más trascendente. Y en estos casos, son decisivas tanto las garantías procedimentales, que reducen el riesgo de error y mejoran la prevención[11], como las exigencias orientadas al conocimiento general *ex ante* de las infracciones y sanciones, en el sentido de la venerable regla del *nulla pena sine lege*.

Las sanciones que imponen las organizaciones privadas (reprensión, suspensión de derechos asociativos, expulsión como castigo más severo) son mucho menos costosas, en su imposición y en su ejecución posterior, tanto en términos sociales como reputacionales, para el individuo afectado[12]. En muchos sentidos, tales sanciones guardan semejanza con las sanciones sociales (ostracismo, murmuración, humillación, etc.) aplicadas informalmente por individuos y colectividades como castigo por el incumplimiento de reglas morales o pautas de comportamiento socialmente compartidas: su coste de imposición y ejecución es típicamente bajo; se refieren a conductas que no requieren detalle técnico en su apreciación, sino que son intuitivamente aprehensibles; son generales y amplias en la contemplación de conductas

[11] Los errores en la aplicación del castigo, con independencia del coste social de las sanciones en sí y del efecto pernicioso de la percepción pública de los errores de la justicia, reducen la eficacia preventiva de las sanciones, al reducir el "coste" relativo en términos de sanción de los comportamientos ilícitos en relación con los lícitos. La *summa* de la teoría económica de la prevención la encuentra el lector interesado en Steven Shavell, *Foundations of Economic Analysis of Law*, Harvard University Press, Cambridge (MA) (2004), recensionado en este mismo número de InDret.

[12] Al contrario de lo que probablemente ocurre en otras sociedades, el impacto reputacional que la expulsión de una asociación o de un centro educativo tiene entre nosotros es, me parece, relativamente escaso. El arrepentimiento, la contrición, el perdón y la enmienda son valores sociales apreciados, no en balde nuestra sociedad es de tradición católica.

sancionables[13]; son esencialmente reputacionales en su mecánica disuasoria; no son consecuencia de un intento sistemático y organizado de detectar y sancionar infracciones de las reglas de conducta aplicables.

El uso de sanciones morales y sociales para prevenir conductas indeseables tiene algunas indicaciones en términos de eficiencia económica[14], pero no es ninguna panacea (no conduce necesariamente, ni mucho menos, al óptimo social en prevención, y puede generar tanto un exceso como un defecto en cotas de prevención). No se puede, por tanto, condenar *a priori*, y por razones de orden teórico, la utilización de controles jurídicos (mediante reglas, procedimientos y órganos del sistema jurídico estatal) *ex post* sobre los procedimientos y resultados de tales mecanismos sancionadores. Al menos cuando el coste de tales controles organizados no sea exageradamente alto[15], como parece ser el caso en relación con las sanciones que imponen los entes asociativos a sus miembros, o los centros escolares a sus alumnos. Además, puestos a que el sistema jurídico intervenga en este ámbito, en términos de eficiencia (acaso también de preservación de los derechos de libertad de asociación, de enseñanza o de empresa subyacentes) mejor es que lo haga en cuestiones de procedimiento que no en cuestiones de fondo o materiales. El caso más patentees de una no muy costosa intervención en ámbitos procedimentales es el del incumplimiento del procedimiento estatutariamente previsto en la norma rectora del ente de que se trate[16].

Sin embargo, una traslación incondicionada o sin matices de las garantías de publicidad y procedimentales del ámbito penal, o incluso del administrativo sancionador[17], al de las sanciones privadas me parece, sin duda alguna, injustificada e indeseable. La adaptación debe ser mesurada y, en términos globales, muy contenida, con detallada consideración de las notabilísimas diferencias (en cuanto a principios jurídicos subyacentes, a dimensión social de las conductas, a relevancia práctica de las alternativas) que hay entre unos y otros instrumentos de sanción de comportamientos. La sentencia que comentamos, al igual que la gran mayoría de las restantes del Tribunal Supremo, tocantes a estos asuntos, ha sido, por el contrario, muy poco reflexiva en la transposición.

---

[13] Por ejemplo, la previsión estatutaria condenada en la citada STS, 1ª, 16.6.2003 se refería a conductas contrarias a la ley, la moral y las buenas costumbres.

[14] Véanse Eric Posner, *Law and Social Norms*, Harvard University Press, Cambridge (MA) (2001); Steven Shavell, *Foundations of Economic Analysis of Law*, Harvard University Press, Cambridge (MA) (2004), p. 613 y ss.

[15] En el caso de las sanciones sociales o morales, lo corriente es que ese coste sea exorbitante y que el sistema jurídico renuncie a interferir con dichas sanciones, salvo en casos extremos de sanciones sociales particularmente ineficientes (el duelo, por ejemplo), o de motivaciones subyacentes a su imposición particularmente condenables (las de naturaleza racista, xenófoba o sexista, por ejemplo).

[16] Por ejemplo, en el caso de la STS, contencioso-administrativa, de 4.7.1984, la expulsión del alumno de un Colegio Mayor se había producido con incumplimiento flagrante de lo dispuesto en los Estatutos del Colegio, y por órgano incompetente, según los mismos Estatutos, para adoptar tal decisión.

[17] E incluso, dicho sea de paso, desde el derecho penal al administrativo sancionador. Para un análisis económico del uso de sanciones administrativas y penales, véase Nuno Garoupa y Fernando Gómez, "Punish Once or Punish Twice: A Theory of the Use of Criminal Sanctions in Addition to Regulatory Penalties", 6 *American Law and Economics Review* (2004).

3. Los remedios frente a la vulneración de los derechos fundamentales y sus fundamentos

Supuesta la vulneración de las garantías y derechos constitucionales referidos en el apartado anterior, se abre ante el Tribunal la cuestión de los remedios para repararla.

En pura teoría, cabría haber acudido a declarar la nulidad del acuerdo de expulsión del centro, condenando a éste a la readmisión del alumno afectado. En el caso de asociaciones, la nulidad de acuerdos y readmisión es remedio muy frecuente en la jurisprudencia del Tribunal Supremo[18], y no es infrecuente en casos de expulsión de alumnos, tanto de centros de enseñanza media como universitarios: SSTS, 3ª, 12.5.1995; 9.7.2001.

En el caso que nos ocupa, la readmisión o restauración *in natura* del derecho vulnerado no parecía una alternativa viable. De un lado, por el principio de congruencia con las pretensiones ejercitadas por los demandantes, que no mencionan la readmisión, sino únicamente la declaración de vulneración y la indemnización de daños[19]. De otro, la tutela en forma específica hubiera resultado muy tardía en este caso: la sentencia del Tribunal Supremo se dicta casi 10 años después de ocurridos los hechos, y aun cuando la sentencia de primera instancia se hubiera ejecutado de forma provisional (arts. 524 y ss. LEC), la virtualidad reparadora efectiva para el alumno afectado hubiera sido enormemente limitada, toda vez que este, muy probablemente, habría ya proseguido los estudios en otro centro y, acaso, hubiera ya concluido el ciclo de estudios de que se tratara.

No se llega a suscitar la cuestión de la propia existencia (pública, por imperativo constitucional) de la sentencia declarativa de la vulneración de los derechos fundamentales del alumno como medio de tutela que pudiera reemplazar, por ejemplo, a la indemnización de daños y perjuicios. La STS, 3ª, 21.3.2003 llega precisamente a esta conclusión: deniega la reparación en dinero de los daños y perjuicios que pretendía el magistrado recurrente, respecto del cual una sanción de suspensión de funciones se anula por la propia sentencia. El argumento aportado es precisamente el del efecto reparador que la propia revocación pública de la sanción tiene sobre la integridad moral del demandante, lo que viene a conceder, por decirlo de alguna manera, *in natura* (conocimiento público de la revocación) lo mismo que el demandante reclamaba por su sustitutivo en dinero.

Sólo le queda, pues, al Tribunal Supremo, la puerta de la indemnización de daños y perjuicios (morales, pero esto es algo de lo que me ocuparé en el apartado siguiente) a los demandantes. Pero la abre con ciertas dificultades de concepto, pues entiende que la responsabilidad del

[18] STS, 1ª, 26.10.1995; 13.6.1996.

[19] Conviene recordar, sin embargo, que el Tribunal Supremo ha negado que exista incongruencia cuando se solicita la reparación en forma específica y el órgano judicial condena a la indemnización de daños y perjuicios, aun siendo el primer remedio materialmente posible: SSTS, 1ª, 17.10.2003; 26.5.2003; 2.12.1998. Y el Tribunal Constitucional ha negado igualmente que en esos casos se vulnere la tutela judicial efectiva del demandante: STC 194/1991, 17.10.1991.

Colegio Rías Altas no es propiamente ni contractual ni extracontractual, sino una especie de *tertium genus*, no encuadrable con precisión ni en una ni en otra categoría, y que denomina como responsabilidad *"… de daños generados en línea de abuso del derecho o de contraderecho…"*[20].

Es muy dudoso que la categoría *ad hoc* que se pretende crear sea útil, ni desde el punto de vista conceptual, ni desde el funcional. Pero lo que es seguro es que en el caso concreto no resultaba necesaria, por cuanto su encuadre sistemático dejaba lugar a pocas dudas: existía un contrato de prestación de servicios concertado entre los padres del alumno y el centro escolar[21], con prestaciones a favor de tercero (el alumno), contrato que ha sido incumplido (por hipótesis, dada la ilicitud de la expulsión) por el Colegio, generándose a su cargo la correspondiente obligación de indemnizar los daños *ex* art. 1101 CC.

Así lo ha venido entendiendo, por otra parte, el propio Tribunal Supremo en casos similares. En el caso de la STS, 1ª, 14.2.1995, la expulsión fulminante de un menor participante en un programa de estudios de verano en los Estados Unidos de América se califica (por la Audiencia, pero el Tribunal Supremo no discrepa de la calificación) de incumplimiento de contrato. Y lo mismo en el caso decidido en la STS, 1ª, 15.2.1994, en la que la relación entre la alumna y el centro de estudios de verano en el extranjero se considera con rotundidad de carácter exquisitamente contractual[22]. El resuelto por la STS, 1ª, 21.11,2002 es, si cabe, aún más ilustrativo. El demandante, alumno de un curso de enseñanza aeronáutica, fue expulsado del mismo como consecuencia de varias faltas de conducta (copiar de una chuleta en un examen, realizar sin motivo ni autorización un aterrizaje no previsto alterando el Plan de Vuelo). Se le aplicó, además, la cláusula penal prevista en el contrato de prestación de servicios para el caso de expulsión, consistente en la pérdida de todas las cantidades abonadas hasta ese momento como retribución de las enseñanzas, incrementadas en un 25%. En la demanda, el piloto frustrado solicita la nulidad de la expulsión, restitución de cantidades y daños y perjuicios. El Tribunal Supremo, al denegar por entero las pretensiones del demandante, califica sin ambages la responsabilidad del alumno de responsabilidad contractual por incumplimiento de un contrato de prestación de servicios. Y, se podría añadir, no de otra manera, *mutatis mutandis*, cabe entender la responsabilidad del centro de enseñanza que, vulnerando las reglas de procedimiento o los motivos de fondo (o ambos, como parece ser el caso en la sentencia que nos ocupa) expulsa a un

[20] Tercer género que ya había anticipado el mismo ponente en una sentencia anterior (STS, 1ª, 27.7.1994), en un caso de responsabilidad de la comunidad de propietarios frente a un comunero, y que había esbozado, *avant la lettre*, la responsabilidad por ocupación de mala fe que elabora la STS, 1ª, 7.12.1990.

[21] La naturaleza de cooperativa del centro escolar puede hacer surgir la duda de si se trata de una cooperativa de padres o de alumnos, en cuyo caso la relación es de naturaleza asociativa, y no de prestación de servicios. La impresión, sin embargo, es que el Colegio en cuestión no es una cooperativa de padres o alumnos, sino de enseñantes (el art. 103 de la Ley de cooperativas prevé ambas modalidades como cooperativas de enseñanza), lo que hace indudable el carácter de contrato de prestación de servicios educativos.

[22] El hecho de que la indemnización lo fuera por daños morales en la sentencia que se comenta no constituye un factor diferencial, pues en ambas sentencias citadas es el daño moral contractual lo que va a ser indemnizado.

alumno poniendo fin de forma no ajustada al contrato la realización de las prestaciones a su cargo[23].

Que las conductas del alumno (o de los padres) que afectan a la disciplina académica del centro, así como las reglas de disciplina académica y las aplicaciones de éstas que aprueba y realiza el centro tienen carácter exquisitamente contractual, me parece difícilmente contestable. Y ello con independencia de la posición que se adopte en la vieja polémica, muy del gusto germánico, acerca del carácter o no de cláusulas penales de las normas de régimen sancionador en el seno de las entidades de carácter asociativo[24]. En el caso de un contrato de prestación de servicios, como en la sentencia que se comenta, la naturaleza contractual de las reglas, las conductas y, en su caso, las responsabilidades, es la solución más natural y transparente[25].

4. Los daños morales como sanción

La indemnización de daños y perjuicios que concede a los demandantes el Tribunal Supremo asciende a 12.000 €, cuya entera cuantía va a compensar, según el Tribunal, los daños morales sufridos por el alumno expulsado y por sus padres.

No constan acreditados daños patrimoniales de ninguna clase. El alumno expulsado, mejor o peor, pudo rehacer su curso de BUP en la enseñanza nocturna y, previsiblemente, no se vio demostradamente perjudicado en su progresión académica[26]. Aunque se intentó, en la instancia no prosperó la acreditación de daños psicológicos (insomnio, depresión) en el alumno, que acaso hubieran requerido tratamientos médicos que cuestan dinero. En definitiva, los daños patrimoniales en el caso eran de pequeña cuantía y, en todo caso, indemostrables en concreto[27].

---

[23] El hecho de que en el contrato entre el alumno y el centro aeronáutico se recogiera expresamente el compromiso del alumno de cumplir las Normas de Régimen Interior, y que el incumplimiento de esa normativa se contemplaba como causa de resolución del contrato a instancias del centro, hacen en ese caso más fácil, pero no distinta, la solución a la que merece el caso de la sentencia de 9.12.2003. ¿O acaso los arts. 1124 y 1258 CC no son precisamente reglas por defecto de la reglamentación contractual específica a estos efectos?.

[24] Véase sobre ello el tratamiento clásico de Karl Larenz, *Allgemeiner Teil des deutschen bürgerlichen Rechts*, 8ª ed. Revisada y ampliada, Munich, Beck (1997).

[25] Y, de paso, refuerza, sin necesidad de acudir al art. 25 CE, las exigencias de publicidad y tipificación, tanto por la vía de las condiciones generales de contrato, como por la vía del control de la interpretación unilateral del contrato contraria al art. 1256 CC.

[26] La sentencia no indica nada al respecto lo que, me parece, es indicio de que no debió haber impacto académico fácilmente acreditable.

[27] Podría darse el caso, incluso, de que en apariencia la economía familiar se hubiera aliviado de un gasto si el segundo colegio hubiera resultado más barato que el primero (lo que era altamente plausible en las circunstancias). Pero sólo en apariencia. El bienestar neto (utilidad de la educación del hijo menos coste de la misma) de los padres tenía que ser mayor en el Colegio Rías Altas que en cualquier otra alternativa, pues de lo contrario no lo habrían enviado allí en primer lugar.

Pero ha habido, a juicio del Tribunal, una vulneración de derechos fundamentales, una conducta arbitraria de la demandada que ha restringido no sólo garantías en el ámbito sancionador, sino el derecho a la educación de un adolescente. La única forma de expresar la desaprobación de la conducta (y de disuadirla, a salvo la preocupación del Colegio por su reputación en el mercado de padres con hijos en edad escolar en A Coruña) que le merece al Tribunal, es la de condenar a la indemnización del daño moral.

Daño moral sin duda hay, tanto para el menor como para sus padres. El efecto negativo sobre la reputación del adolescente a causa de ser expulsado por motivos aparentemente relacionados con el consumo de drogas parece poco cuestionable, en particular en una ciudad de algo menos de un cuarto de millón de habitantes como es A Coruña. En cuanto a los padres, qué duda cabe que la expulsión tuvo que provocar preocupación, lo que supone una reducción del bienestar personal que típicamente el dinero y los bienes materiales sustituyen malamente. La sentencia, para retratar la zozobra de los padres, habla de desazón, inquietud, intranquilidad, desasosiego, sobresalto, hasta de pesadilla, en relación con la situación y futuro escolar de su hijo. El evidente exceso descriptivo y la ampulosidad estilística del Tribunal Supremo no son, creo, sino instrumentos[28] que persiguen atenuar bajo el velo de la compensación del dolor y la angustia lo que esencialmente es una sanción de un comportamiento –el del Colegio- que se considera intolerable[29]. Es cierto, pues, que nuestro sistema jurídico no conoce los daños punitivos, acaso hasta a muchos les horroriza la institución en lo que tiene de híbrido (no de *tertium genus*, que no es). Pero la utilización real de la condena a indemnizar los daños morales recuerda en muchos casos, como en el de esta sentencia, que los Tribunales civiles no pueden sustraerse del todo a la tentación de castigar lo que rechazan.

[28] Retóricos, o literarios, si se prefiere, para obtener el resultado deseado sin mostrar todas las cartas. Algo que el discurso jurídico, judicial y no judicial, practica con asiduidad. Sobre el uso de recursos retóricos paralelos a los literarios en el Derecho, véase Anthony Amsterdam y Jerome Brunner, *Minding the Law*, Harvard University Press, Cambridge (MA) (2000).

[29] A título de comparación, la STS, 3ª, 1.4.2003, condena a pagar nada más 500.000 pesetas a dos agentes de la policía local de Pineda de Mar por la anulación de sus nombramientos y plazas, sufriendo incluso uno de ellos una depresión médicamente contrastada. Pero la conducta del Ayuntamiento había sido meramente torpe, no reprobable.

5. Tabla de sentencias citadas

Tribunal Constitucional

Sala y Fecha	*Ref.*	*Magistrado Ponente*	*Partes*
2ª, 14.6.1999	104/1999	Rafael de Mendizábal Allende	Asociación "Disminuidos Físicos de Aragón" c. socios de la asociación.
2ª, 16.11.1998	218/1998	Rafael de Mendizábal Allende	Ayuntamiento de Benidorm c. "Incoplan, S.A.".
2ª, 21.3.1994	96/1994	Julio Diego González Campos	Sociedad Cooperativa Limitada de Viviendas Molnedo c. Julio.
1ª, 17.10.1991	194/1991	Fernando García-Mon y González Regueral	José Antonio c. María Rosario y la Entidad "Hullera Vasco-Leonesa, S.A.".
2ª, 23.2.1987	23/1987	Angel Latorre Segura	"Larios, S.A." c. Pilar.

Tribunal Supremo

Sala y Fecha	*Ref.*	*Magistrado Ponente*	*Partes*
1ª, 17.10.2003	7395	Jesús Corbal Fernández	Comunidad de Propietarios c. "Dragados y Construcciones, S.A.".
1ª, 16.6.2003	5640	Antonio Romero Lorenzo	"Club San Marcos de Almendralejo" c. José Enrique y Luis Manuel.
1ª, 26.5.2003	7154	Antonio Romero Lorenzo	Álvaro c. Luis Carlos.
3ª, 1.4.2003	3662	Francisco González Navarro	Alonso y Christian c. Ayuntamiento de Pineda de Mar.
3ª, 21.3.2003	3653	Nicolás Maurandi Guillén	Luis Alfredo c. Acuerdo del Pleno del CGPJ.
1ª, 21.11.2002	10269	Jesús Corbal Fernández	Carlos c. "SENASA, S.A.".
3ª, 9.7.2001	7772	Ramón Trillo Torres	Ignacio c. Universidad Nacional de Educación a Distancia.
1ª, 2.12.1998	9701	Luis Martínez-Calcerrada y Gómez	Manuel c. Luis.
1ª, 13.6.1996	4761	Luis Martínez-Calcerrada y Gómez	Francisco y Antonio c. PSOE.
1ª, 26.10.1995	7849	Alfonso Barcalá Trillo-Figueroa	Manuel Jaime c. "Casino de Madrid" y otros.
3ª, 12.5.1995	5286	José María Morenilla Rodríguez	Carlos Alberto c. Consejo escolar del Instituto "ED" de Logroño.
1ª, 14.2.1995	1104	Jesús Marina Martínez-Pardo	Raúl c. "E.F. Colegios Europeos de Verano, SA".
1ª, 27.7.1994	6787	Alfonso Villagómez Rodil	Antonio c. Comunidad de Propietarios.

1ª, 15.2.1994	1308	Alfonso Villagómez Rodil	Gabriela Josefa c. "Yago School Limited".
1ª, 16.12.1991	491	Gumersindo Burgos Pérez de Andrade	Francisco, Manuel y Josefa c. Ministerio Fiscal y la "Lliga de Catalunya de Mutilats i Viudes de la Guerra d'Espanya".
1ª, 17.12.1990	10279	Jesús Marina Martínez-Pardo	Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia c. "Unión Provincial de Auto-Taxis y Auto-Turismo de La Coruña".
1ª, 7.12.1990	9900	Ramón López Vilas	"INVEMAR, S.A." c. Roberto y su esposa (no consta identidad).
3ª, 4.7.1984	5626	José Garralda Valcárcel	Mª Pilar c. Colegio Mayor "Residencia Asturias".